

1501322-87.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... e viciante, e por sua maior dedicação ao tráfico, segundo ele seria seu terceiro dia no tráfico, já que trabalhara no fim de semana, opto pelo redutor de 1/3, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501322-87.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/000945

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2179814/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 2179814 - 03º D.P. DIADEMA, 2228/21/127 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Daniel Dantas da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

CARLOS DANIEL DANTAS DA SILVA, qualificado à fl. 15, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 03 de julho de 2021, por volta das 23h54, na Passagem Salsa e Merengue, n.º 130, bairro Vila Nogueira, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 177 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 46,15 gramas, 55 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 10,5 gramas e 322 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 1.945,43 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de constatação de

fls.06/08.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.48/50), foi nomeado Defensor Público ao réu, estando a defesa inicial às fls.118/120. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 11/11/2021 (fls. 139) e certificadas a notificação e a citação positivas do Réu (fls. 104).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida uma testemunha comum, homologada a desistência das Partes quanto à oitiva do policial Vinicius Pereira, adoentado, e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência parcial da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima bem acima do mínimo diante da excessiva quantidade e nocividade das drogas, dentre elas a cocaína, com as atenuantes da menoridade relativa e confissão, afastando-se a agravante da calamidade pública, concordando com a redução da pena em patamar mínimo, sem sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional intermediário, e perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com o redutor da pena em percentual máximo, e sua substituição nos moldes do art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, com a ressalva de ser hipótese de se afastar a agravante da calamidade pública, por falta de prova cabal do nexos causal, como veremos adiante.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.22, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 09/11 e 101/103), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína na forma de pó e pedra.

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 04/06) efetuavam patrulhamento ostensivo preventivo pela Passagem Salsa e Merengue, Bairro Vila Nogueira, esquina com a Rua Dom Jorge Mascarenhas, local de incidência de tráfico de drogas. Visualizaram um indivíduo carregando um mochila nas costas, e que ao perceber a presença policial demonstrou nervosismo, inquietude e hesitação, caracterizando atitude suspeita e motivado a abordagem policial. Proferiram voz de parada ao mesmo, que não obedeceu e começou a correr por cerca de 100 metros, sendo perseguido e detido na altura do numeral 130 da Passagem Salsa e Merengue. Procederam a busca pessoal no indivíduo, posteriormente identificado CARLOS DANIEL DANTAS DA SILVA, e localizaram no interior da mochila que ele carregava, 322 tabletas de erva esverdeada com características de Maconha, 117 microtubos contendo substância em pó branca com características de Cocaína, 55 Invólucros plásticos contendo pedras amareladas com características de Crack, além da quantia de R\$ 14,00 em moedas, um aparelho celular marca Samsung. Indagado informalmente, ele confessou que estava traficando drogas naquele local.

O miliciano Princy de Oliveira, narrou em juízo que o local é um ponto de tráfico.

O réu viu a equipe e fugiu. Foi alcançado, e com ele estava uma mochila contendo drogas. Foi a primeira vez que o viu no local.

O réu, em solo policial (fl.07) respondeu que estava traficando as drogas que trazia dentro da mochila quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar. Que recebe dez por cento do valor arrecadado, cerca de R\$ 200,00 por dia. Disse que as drogas são entregues pelo gerente da biqueira da Rua Quarenta e Um, mas não sabe o nome do patrão. E que está vendendo drogas há três dias.

Em juízo o acusado confessou que se deixou levar por amigos, aceitou e ficaria só um fim de semana, e está arrependido. Nunca foi processado antes.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e transportar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 65/66), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas sim a excessiva quantidade do narcótico apreendido (554 porções totais), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena acima do mínimo, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim as atenuantes da menoridade relativa (fl. 18) e da confissão, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à agravante do art. 61, II, "j", do CP, embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, entendo não haver prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitiva, até porque a biqueira já existia antes de sua prisão e assim persiste até a presente data, independente portanto, da pandemia.

Neste sentido vide: Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a agravante de crime cometido em período de calamidade

pública, conforme o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, segundo o relator, desembargador Andrade Sampaio, "não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19" (TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.30/32), mas considerando seu maior envolvimento com a traficância conforme o valor em dinheiro trocado encontrado em seu poder a indicar vendas efetivamente efetuadas a usuários, propagando o vício, somado à natureza da droga, especialmente o crack, de alto poder lesivo e viciante, e por sua maior dedicação ao tráfico, segundo ele seria seu terceiro dia no tráfico, já que trabalhara no fim de semana, opto pelo redutor de 1/3, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

O quantum da condenação, a primariedade, a confissão, a menoridade relativa de um lado, mas de outra banda a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, e a grande quantidade e variedade de drogas indicam que o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deva ser no regime semiaberto, a teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, especialmente pela preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019). Incabível contudo, a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando socialmente recomendável tal benesse diante da elevada culpabilidade, especialmente para não potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade, por violar mais intensamente o bem jurídico tutelado, e dado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem da prática de delitos de tráfico um verdadeiro meio de vida. Ademais: O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante

que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por estar traficando há pelo menos três dias, e constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal dos acusados, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, o réu está preso há seis meses, sem direito à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra CARLOS DANIEL DANTAS DA SILVA, qualificado à fl. 15, como incurso somente nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e não também quanto à agravante do art. 61, II, “j”, do CP que ora o absolve com fulcro no art. 386, VII, do CPP, condenando-o pelo tráfico de entorpecentes, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O acusado não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fls. 65/66), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa. Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA